

0000520-55.2022.8.26.0594

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Comarca: Assis

Foro: Foro de Assis

Vara: 3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... a Everton, pois utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas.

Ressalto que o E. Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que: "é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Assis

Foro de Assis

3ª Vara Criminal e da Infância e Juventude de Assis

Rua Doutor Lycio Brandao de Camargo, 50, Assis-SP - cep 19802-300

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000520-55.2022.8.26.0594 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000520-55.2022.8.26.0594

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência - DP7815-1/2022 - DEL.SEC.BAURU

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Reginaldo Machado da Silva e outros

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Arnaldo Luiz Zasso Valderrama

Vistos.

O Ministério Público do Estado de São Paulo ofereceu denúncia contra Everton Ribeiro de Moraes, Reginaldo Machado da Silva e Leonardo Amaro Pires, qualificados nos autos, por terem, em tese, praticado o delito tipificado no art. 33, "caput", c.c. art. 40, V, ambos da Lei n. 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal. Narrou que no dia 15 de julho de 2022, por volta das 11h, na Rodovia Rachide Raies, Km354, na cidade de Echaporã, nesta Comarca, Everton, Reginaldo e Leonardo, transportavam 66,976kg de maconha. Segundo apurado, os denunciados foram até Nova Esperança/PR com o veículo C4 Pallas, aonde fariam o carregamento de droga e levariam até Bauru/SP; transportariam em dois veículos, Leonardo com o Citroen C4

Pallas, levando os 96 tabletes de maconha e, Everton e Reginaldo no Ford/Fusion, sem entorpecente, na função de batedor; policiais da DISE-DEIC Bauru receberam notícias do transporte de entorpecentes, posicionaram-se na praça do pedágio disfarçados como funcionários, abordaram e identificaram ambos denunciados, que foram presos; momentos depois, ao passar pela praça de pedágio, na condução do C4 Pallas, Leonardo percebeu que estava sendo seguido por viatura e fugiu em alta velocidade; em um acesso de terra ele estacionou o veículo e evadiu-se a pé; ele se apresentou na Delegacia no dia 20 de julho de 2022 e confessou a prática delitiva. Notificados, os réus apresentaram defesa (fls. 299/302, 312/320 e 362/364).

A denúncia foi recebida em 12/09/2022 (fls. 425/429).

Em audiência realizada no dia 03/10/2022 foi feita a oitiva de testemunhas e os interrogatórios dos réus (fls.515/516).

Em alegações finais, o douto membro do Ministério Público pediu a condenação dos réus. Aduziu que os policiais foram uníssonos em seus depoimentos e não tinham intenção de prejudicar os réus; a versão de Leonardo não deve prosperar, em solo policial ele deu detalhes da empreitada criminoso o que pode ter gerado ameaças para mudar sua versão; os veículos passaram pela praça de pedágios com diferença de cerca de 10 minutos corroborando os relatos de Leonardo em solo policial. Pediu a exasperação da pena-base para todos os réus em razão da elevada quantidade de drogas e para Everton em razão de possuir maus antecedentes; na segunda fase a agravante da reincidência com relação a Everton; e o aumento de pena pelo tráfico interestadual; a fixação do regime inicial fechado; o afastamento dos benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal e a manutenção da prisão preventiva (fls.519/523).

A douta Defesa do réu Reginaldo pleiteou a improcedência. Sustentou que nada de ilícito foi encontrado com ele; Everton disse na delegacia que foi até Maringá pegar um carro que havia vendido na garagem, desfez o negócio e chamou Reginaldo para o acompanhar porque não é habilitado; André negou ter certeza que Reginaldo seria o indivíduo que embarcou no C4 Pallas, o escrivão pode ter errado o termo de depoimento ou entendido errado seus relatos; Everton e Leonardo confirmaram que saíram de Bauru no C4 Pallas e o policial relatou que duas pessoas teriam embarcado no carro, evidenciando que Reginaldo não mentiu quando disse que foi até Maringá de ônibus; as provas são frágeis. Subsidiariamente, requereu a pena no mínimo legal; é tecnicamente primário, pois seus antecedentes já datam mais de 5 anos; o reconhecimento do tráfico privilegiado; e a fixação de regime prisional diferente do fechado (fls.533/540).

A douta Defesa do réu Everton pediu a improcedência. Arguiu que nada de ilícito foi encontrado com ele; Everton narrou que pediu a Leonardo que o levasse até Sarandi-PR onde visitaria sua filha e depois traria de volta um veículo que vendeu e desfez o negócio; Reginaldo foi na frente para pegar o veículo em Maringá, buscar Everton e retornar a Bauru; André afirmou que não conhecia Everton, mas os colegas haviam comentado sobre ele; Everton estaria no C4 Pallas com indivíduo parecido com Reginaldo; Everton e Leonardo confirmaram que saíram de Bauru no C4 Pallas e o policial relatou que duas pessoas teriam embarcado no carro, evidenciando que Reginaldo não mentiu quando disse que foi até Maringá de ônibus; as provas são frágeis. Subsidiariamente, pediu a pena no mínimo legal; o reconhecimento do tráfico privilegiado; e a fixação de regime prisional diferente do fechado (fls.524/532).

A douta Defesa do réu Leonardo alegou que: ele confessou o crime; Everton e Reginaldo não tinham envolvimento com o carregamento; conhece Everton do bairro em que residem e desconhece Reginaldo; aceitou dar carona para Everton, pois precisava do valor das despesas, já que teria que realizar a viagem para o transporte das drogas; o veículo pertence a sua avó que não tinha ciência dos fatos. Pediu a atenuante da confissão; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a fixação do regime inicial diverso do fechado com substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito e o direito de recorrer em liberdade (fls.541/558).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, passo ao julgamento do mérito. A pretensão veiculada nesta ação penal é procedente.

A materialidade do delito de tráfico de drogas foi comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão (fl.16/17), laudo de constatação provisória (fls.19/26), laudo toxicológico (fls.162/167). Extrai-se do laudo que foram periciados fragmentos vegetais, cujo resultado foi positivo para Tetrahidrocanabinol – THC, substância de uso proscrito no Brasil. A autoria é certa e atribuída aos três réus, conforme prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Em seu interrogatório Leonardo confessou o crime. Afirmou que havia recebido uma proposta antes de ir para o Paraná, mas não tinha dinheiro para fazer a viagem não fez. Relatou que a proposta era para fazer carregamento no Paraná, não pode falar quem fez. Negou que o Everton tenha tido participação, ele falou que tinha que buscar um Ford Fusion e o corréu lhe deu a despesa para viajar e sua alimentação lá. Disse que depois foi buscar a droga e o depoente voltou sozinho. Negou ter voltado com o Everton, não teve mais contato com ele. Negou ter falado que os corréus atuaram como batedor, tinha outro advogado e ele lhe orientou a depor que não iriam lhe prender, só chegou e assinou os papéis. Negou ter dito sobre o batedor, nem sabe o que é isso. Contou que pegou no Paraná e levaria até Bauru, por R\$ 5 mil. Narrou que conhece apenas Everton, o Reginaldo não conhece. Negou ter passagem criminal. Negou saber o motivo de os policiais falarem que deu versão diversa, não teve problema com eles. Negou ter como explicar o motivo pelo qual constou no depoimento que ganharia R\$ 5 mil. Falou que eles combinaram para deixar o carro no posto em Bauru e pegar no outro dia. Negou ter outro no carro durante a viagem. Frisou que o carro C4 era da avó e não tinha costume de usá-lo. Negou ter contato de Reginaldo. Ressaltou que apenas o depoente e Everton desceram ao Paraná, não havia mais ninguém, não viu o Reginaldo lá. Negou ter pernoitado no Paraná. Afirmou que trabalhava na empresa de gesso e ganhava em torno de R\$ 2 mil. Negou ter dinheiro para ir ao Paraná.

Reginaldo negou o crime. Afirmou que viajou para o Paraná um dia antes dos fatos, saiu de Botucatu, veio até Bauru e almoçou, seguiu até a rodoviária para ver horário de ônibus, não tinha disponível. Relatou que ligou para o amigo e ficou esperando dar o horário para Maringá, viajou de ônibus dia 14. Mencionou que foi para Maringá a pedido do Everton, ele tem problema de habilitação e tinha vendido o Fusion, porém havia uma restrição de leilão, teria que buscar ele. Disse ter ficado numa pousada, depois o pegou em Sarandi na casa dos familiares e vieram embora. Negou ter atuado como batedor, sempre trabalhou desde pequeno com carteira registrada, só numa empresa, como representante comercial, motorista, balconista e auxiliar de farmácia. Contou que estava com artrite reumatóide e aguardava perícia para obter benefício. Narrou que conhece Everton há oito anos, em Bauru, na época trabalhava. Salientou que fez o favor porque estava desempregado. Ressaltou que essa pessoa veio até o depoente onde estava e deixou o carro com ele, depois foi buscar o corréu em Sarandi. Negou conhecer o réu Leonardo e ter trocado mensagem com ele. Negou ter tido contato com o C4 Pallas. Esclareceu que recebeu auxílio-doença pela sua doença. Negou ter feito transferência para conta a pedido de Everton. Negou ter sido condenado. Salientou que na época dos fatos aguardava agendar a perícia do INSS.

O réu Everton negou o crime. Afirmou que a viagem foi motivada por uma venda de um carro em Maringá, o garagista detectou um leilão no documento do carro e não quis ficar com o carro. Relatou que o Reginaldo tem habilitação e o depoente é desabilitado, chamou-o para ir e aproveitou para ficar com a filha que mora em Sarandi. Mencionou que chamou o Leonardo para ir com o depoente, um dia antes fez pagamento a ele para arcar com despesas de gasolina, pedágio e alimentação e pediu a ele para deixar em Sarandi, pagou R\$ 1300 salvo engano, R\$ 1350, para pagar despesas de ida e volta. Declarou que Reginaldo foi dois dias antes de ônibus, não foi com o depoente, foi para acompanhar a vistoria que o rapaz da garagem ia fazer. Negou saber do transporte da droga, Leonardo deixou em Sarandi e não sabe para onde ele foi. Disse que foi abordado no pedágio de Marília e não sabia do motivo da apreensão. Salientou que o Leonardo apareceu uns 40 minutos depois da abordagem no

pedágio. Negou ver motivo para Leonardo lhe prejudicar, para ele ficar na rua tinha que jogar em alguém, rolou pressão dos policiais e ele falou isso. Confirmou que primeiro pediu ao Leonardo levar e pagou R\$ 1300 a ele para despesa da viagem e alimentação, não sabe onde ele foi. Esclareceu que não chamou ele para voltar porque Reginaldo já estava lá há dois dias para acompanhar a vistoria. Narrou que estava desempregado, fazia venda de carros e ganhava comissão. Ressaltou que tem cinco filhos. Afirmou que o rapaz que lhe vendeu o carro não passou a procedência e tentou vender sem saber disso, os garagistas de Maringá identificaram e não quiseram pagar a Tabela Fipe. Relatou que era comum fazer isso no Paraná porque morou muito tempo lá, é o único lugar que paga em cima da Tabela, lá queriam pagar muito abaixo do preço. Mencionou ter recebido documento da vistoria citando o leilão. Declarou que ia ver a filha no Paraná de três em três meses, a avó e o irmão moram em Maringá, a família era de lá. Narrou que já foi condenado em 2011 por roubo.

A testemunha André afirmou ter recebido informação de que Everton ia buscar carregamento de drogas usando a Rota Bauru Marília e passaram a monitorá-lo. Relatou ter percebido que ele estava acompanhado por indivíduos, um tinha grande semelhança com Reginaldo, eles foram em direção à Marília. Mencionou que no deslocamento os perderam de vista e se posicionaram na rodovia, pois sabiam que eles voltariam daquela região com carregamento de drogas. Narrou que eles estavam num carro C4. Disse que durante a madrugada recebeu informação de que Everton voltaria à frente num carro modelo Fusion e a droga voltaria atrás no C4. Contou que ao avistar o carro Fusion os abordou e dentro dele estavam Reginaldo e Everton, pouco atrás estava o C4. Acrescentou que ao perceber a abordagem ele acelerou muito e o perseguiu. Frisou que encontrou cerca de 70 kg de maconha no veículo C4. Informou que viu saindo de Bauru com certeza o Everton, o outro era muito semelhante ao Reginaldo. Afirmou que pouco tempo depois dos fatos Leonardo apareceu na Delegacia e se responsabilizou pelo veículo C4 onde acharam a droga, ele falou que o carro era da avó e ele usava sem o conhecimento dela. Relatou que ele admitiu ter sido convidado pelo Everton para buscar um Ford Fusion no Paraná, mas chegando lá Everton lhe disse para trazer as drogas, é uma cidade que fica na divisa dos Estados. Mencionou que ele e o colega concordaram em fazer essa viagem de volta, segundo Leonardo estava um pouco relutante, mas como os colegas concordaram ele também aceitou. Narrou que segundo o réu o veículo Fusion atuou como batedor. Esclareceu que alguns colegas conheciam Everton dos meios policiais, mas o depoente não o investigou, os demais também não. Salientou que até o momento não tinha informações sobre quem estava no C4, dias depois ele foi até a Delegacia na companhia de um Advogado e confirmou que teria ido a Marília ou Assis buscar um Fusion e chegando lá o Everton mudou a conversa e pediu para que o Leonardo também trouxesse drogas em seu veículo enquanto o Fusion atuava como batedor. Negou que Leonardo tenha identificado os comparsas que estavam com ele. Declarou que o C4 tinha saído em alta velocidade, o C4 atinge mais de 200 km/h, fizeram acompanhamento de forma segura e quando chegaram ao C4 estava apenas com a droga. Contou que fizeram campana, quando chegou a informação monitoraram o Everton e o viu com algumas pessoas, uma era semelhante ao Reginaldo, constou diferente no depoimento talvez por falha do escrivão ou por um lapso devido ao cansaço por ter varado a noite. Disse crer que Reginaldo não vinha a Bauru sem motivo e estava junto com o Everton para trazer as drogas. Afirmou que na abordagem o Reginaldo e o Everton passaram informações desencontradas, não se recorda exatamente quais, sobre o motivo pelo qual estavam viajando. Relatou que foram os outros colegas que estavam no pedágio que fizeram a vistoria, o depoente ajudou. Negou ter achado algo ilícito no carro conduzido por Reginaldo e em revista dele. Disse que pelo que puxou da ficha de Leonardo ele é trabalhador e foi corrompido pelas más amizades, ele tem família boa. Negou ter conhecimento do envolvimento dele em situações anteriores. Negou ter acompanhado o depoimento dos réus na Delegacia, somente o que falaram na abordagem. Negou se lembrar de ter apurado informações sobre os documentos do Fusion, estava focado na apreensão da droga.

A testemunha Belarmino afirmou que conhece Reginaldo desde 2008. Relatou que o depoente tem comércio em Botucatu e o réu trabalhava numa farmácia. Mencionou que o

réu estava desempregado. Negou saber se ele possui relação com drogas. Negou saber de fato que desabone a conduta dele. Falou que o réu hoje está divorciado, antes disso frequentou a casa dele. Esclareceu que o réu já trabalhava na farmácia antes de o conhecer e trabalhou pelo total de 15 anos. Negou saber se Reginaldo jogava pôquer.

O informante Fábio afirmou que é pai do Leonardo. Relatou que o depoente é motorista de caminhão e o filho trabalhava na mesma empresa e viajava junto, no dia dos fatos ele estava de folga. Mencionou que ficou sabendo do ocorrido através da vó dele, o filho não falou nada. Disse que o Leonardo sempre trabalhou, ajudava num estacionamento, desde pequeno, trabalhava na empresa há um ano e meio e fazia bico entregando lanche à noite. Declarou ter se surpreendido, ele sempre teve tudo da família e trabalhava. Negou conhecer os corréus. Narrou que o C4 Pallas é da avó do Leonardo. Negou que ele tenha pedido autorização para usar, a avó falou que ele pegou e não sabia o que tinha acontecido, soube quando o Leonardo ligou avisando que tinha estragado a vida dele. Contou que Leonardo tem filha de 4 anos e paga pensão.

A testemunha Riciele afirmou que conhece o Leonardo, pois trabalhou para a depoente dois anos como motoboy, a última vez foi há dois meses. Mencionou que não tem do que se queixar dele, é bom funcionário e nunca tinha reclamação dos clientes para quem ele entregava lanche, nunca faltou e nem atrasou. Negou saber de envolvimento dele com ilícitos.

A testemunha Elizabeth afirmou que é avó da esposa do réu Everton. Afirmou que o réu foi em sua casa ficou dois dias e foi embora. Relatou que ele foi visitar a filha dele que mora com a depoente desde quando tinha uns 6 anos, há cinco anos. Mencionou que o réu estava sozinho nessa viagem. Declarou que às vezes o réu vem uma vez por mês. Falou que o réu tinha mandado arrumar um carro e foi buscar, o carro estava na cidade. Contou que o réu fazia bicos e quando registrado era encanador, perdeu o emprego pela pandemia. Disse que o réu mandava dinheiro, mas agora complicou e estava difícil de mandar. Frisou que o réu tem cinco filhos, todos pequenos. Narrou que o réu ficou parado, só tinha aquele carro que estava estragado.

Pois bem. O tráfico de entorpecentes se configura com a prática de várias condutas previstas no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e, como tipo misto alternativo que é, a incidência em qualquer delas justifica a violação do bem jurídico protegido. Desnecessário, portanto, o flagrante do momento da efetiva tradição ou venda do entorpecente para incidência do tipo penal. As condutas periféricas à efetiva comercialização, como trazer consigo, guardar, transportar ou manter em depósito, por exemplo, são suficientes à transgressão do ilícito penal.

Os fatos foram comprovados pela prova oral. O policial André narrou que faz parte da equipe da DISE de Bauru e monitorou Everton, pois tinha recebido informação de que ele buscava drogas se utilizando da rota Bauru-Marília. Ele contou tê-lo visto num veículo C4 Pallas, acompanhado por pessoas, um deles era semelhante ao Reginaldo. Informou que o perderam de vista e durante a madrugada receberam novas informações de que Everton voltaria em um Ford Fusion, na função de batedor do C4 Pallas, que viria atrás com as drogas. O policial parou o Fusion e nele estava Everton e Reginaldo. Contou que pouco atrás estava o veículo C4 Pallas, que ao perceber a abordagem fugiu em alta velocidade e foi encontrado abandonado mais a frente, com cerca de 70kg de maconha. Posteriormente compareceu Leonardo na delegacia e confessou o crime, asseverando que Everton e Reginaldo participavam como batedores.

Os relatos do policial André estão em consonância com os depoimentos do policial João Carlos e do acusado Leonardo, em solo policial.

Ressalto que os depoimentos dos policiais têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais, sendo totalmente descabido o preconceito acerca dos seus depoimentos, sob o pretexto de que viriam a Juízo com o intuito mentiroso, a fim de legitimar suas condutas pretéritas que teriam ensejado a prisão do réu.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável

eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de se tratar de Agentes Estatais incumbidos do dever da repressão penal (Rel. Carlos Bueno, RJTACRIM 49/263).

Na verdade, inexistente qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais ou guardas civis. Não há elemento indicativo de que os policiais quisessem incriminar gratuitamente o réu e não se pode desmerecer a fala só por pertencerem aos quadros da Polícia. Foram submetidos ao contraditório como qualquer testemunha. Seria contrassenso o Estado dar-lhes crédito para atuar na prevenção da criminalidade e lhes negar esse mesmo crédito quando, perante o Estado-juiz, dão conta de suas atividades.

Guilherme de Souza Nucci leciona sobre a validade dos depoimentos dos policiais: "(...) preceitua o art. 202 do CPP que 'toda pessoa pode ser testemunha', logo, é indiscutível que os policiais, sejam eles os autores da prisão do réu ou não, podem testemunhar sob o compromisso de dizer a verdade e sujeitos às penas do crime de falso testemunho" (in Leis Penais e Processuais Penais comentadas, 2ª ed., São Paulo: RT, 2007, p.323).

Nesse sentido, por sinal, a jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal:

"HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS DE ACUSAÇÃO. DEPOIMENTOS PRESTADOS EM JUÍZO POR AUTORIDADES POLICIAIS. VALIDADE. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações." (STF, HC 87.662-5/PE Rel. Min. Carlos Ayres Britto j.05.09.06 DJU 16.02.07, destaquei).

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos." (STF, HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p.39.846, destaquei).

Na mesma linha é o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. EXAME DE CORPO DE DELITO. ART. 158 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESNECESSIDADE QUANDO PRESENTES PROVAS OUTRAS NOS AUTOS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. PRECEDENTES DO STJ E STF. ALEGADA NULIDADE INEXISTENTE. [...]. CORRUPÇÃO ATIVA. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVA. TESTEMUNHO DOS POLICIAIS OFENDIDOS. VALIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOBSERVÂNCIA. [...] 3. Embora existam críticas acerca do valor das declarações prestadas pelo ofendido - no caso os policiais, representado o Estado Administrador/sujeito passivo do crime -, é certo que tal elemento de prova é admitido para embasar o édito condenatório, mormente em casos nos quais a conduta delituosa é praticada na clandestinidade, desde que sopesada a credibilidade do depoimento. 4. Nesse contexto, e com maior razão, esta Corte tem entendimento pacífico no sentido de que o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo a dar azo à condenação, principalmente quando corroborada em juízo. 5. Ordem denegada. (STJ HC 177.980/BA 5ª T. Rel. Min. Jorge Mussi j. 28.06.2011, destaquei).

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ARTS. 33, DA LEI N.º 11.343/06, 304 E 333, DO CÓDIGO PENAL. TESE DE FRAGILIDADE DA PROVA PARA SUSTENTAR A ACUSAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA.

NECESSIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. ILEGALIDADE DA DOSIMETRIA DAS PENAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. O exame da tese de fragilidade da prova para sustentar a condenação, por demandar, inevitavelmente, profundo reexame do material cognitivo produzido nos autos, não se coaduna com a via estreita do writ. 2. Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal. [...] (STJ HC 149.540/SP, 5ª T. Rel. Min. Laurita Vaz j. 12.04.2011, DJU 04.05.2011, destaquei).

“O depoimento de policiais é elemento idôneo à formação da convicção do magistrado quando em conformidade com as demais provas dos autos”. (STJ AgRg no AREsp 262.655/SP 5ª T. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze j. 06.06.2013 DJU 14.06.2013, destaquei).

Destaco que André foi coerente sempre que ouvido e seus relatos harmônicos entre si, não havendo prova em contrário que possa abalar a credibilidade de seu depoimento, onde afirmou que Everton e Reginaldo foram flagrados na função de batedor do veículo conduzido por Leonardo, carregado com vultosa quantia de maconha.

As demais testemunhas ouvidas em juízo, apesar de atestarem a boa índole dos acusados, em nada acrescentaram sobre os fatos objetos destes autos, pois não sabiam das circunstâncias do crime.

De outra banda, a tentativa dos réus, de convencer que apenas Leonardo é culpado é inverossímil. Na fase inquisitiva, a Autoridade Policial colheu a versão de Leonardo na presença de Advogado constituído, oportunidade em que o réu confessou de maneira ampla e detalhada a imputação (apesar de tê-lo feito diminuindo sua culpabilidade) e afirmou que Everton e Reginaldo participaram do crime, na função de batedores.

Em Juízo passou a negar a prática delitiva dos comparsas, assumindo toda a responsabilidade pelo ilícito. Não se cogita que Leonardo tenha mentido em solo policial apenas para se livrar solto, porque a confissão extrajudicial, que serviu para indiciamento, foi corroborada pela prova colhida sob o crivo do contraditório. Ademais, não é razoável acreditar que Leonardo compareceria até a delegacia para confessar o crime e acusar injustamente Everton e Reginaldo apenas para ficar em liberdade, especialmente porque ele já havia logrado êxito em sua fuga sem ser identificado e não foi delatado pelos comparsas.

Em caso similar, o Tribunal de Justiça já asseverou a legalidade da confissão extrajudicial, quando amparada em outros elementos de provas constantes nos autos:

PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO. CONDENAÇÃO LEGÍTIMA. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS. Inexistência de álibi. Absolvição por falta de provas. Impossibilidade Materialidade delitiva e autoria cabalmente comprovadas. Confissão Extrajudicial em harmonia com demais provas. Posterior retratação Irrelevância. Confissão é válida pelo seu teor e não pelo local em que efetuada. Réu primário a época do crime. Dosimetria que comporta pequena correção na primeira fase. Manutenção do regime inicial fechado. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; Apelação Criminal 1508036-17.2018.8.26.0554; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; j.: 16/02/2022, destaquei).

Não há qualquer ilegalidade em lastrear a condenação, também, na confissão extrajudicial, porquanto se amoldou com as demais provas produzidas em instrução. O depoimento do policial excluiu qualquer possibilidade de vícios quando do interrogatório. Não há de se cogitar, pois, violação ao artigo 155 do Código de Processo Penal. Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RETRATAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO COM

BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CONFIRMARAM A CONVICÇÃO DO JULGADOR. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. Não configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a condenação baseada em confissão extrajudicial retratada em juízo, corroborada por depoimentos colhidos na fase instrutória. Embora não se admita a prolação do édito condenatório com base em elementos de convicção exclusivamente colhidos durante o inquérito policial, tal situação não se verifica na hipótese, já que o magistrado singular e o Tribunal de origem apoiaram-se também em elementos de prova colhidos no âmbito do devido processo legal” (STJ, Habeas Corpus 15255/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, Julgado em 20/05/2010, destaquei).

A nova versão contada por Leonardo em juízo é inverossímil. Ele afirmou que teria recebido uma proposta para realizar o transporte de drogas, mas não tinha dinheiro, o que soa estranho para alguém que tinha trabalho lícito. Leonardo narrou que Everton lhe disse que tinha que ir até o Paraná buscar um Ford Fusion, Leonardo se propôs a levá-lo e Everton pagou suas despesas com a viagem e alimentação. Everton disse em seu depoimento que o valor pago foi de R\$ 1300 ou R\$ 1350, não se recorda. Leonardo asseverou que depois que deixou Everton em seu destino, carregou o veículo com drogas e foi embora, sem manter novo contato com ele.

Todavia, não é crível que Everton pagaria R\$ 1300 a título de despesas a Leonardo apenas para levá-lo até Maringá. Primeiro porque a distância entre Bauru e Maringá pelo Google Maps é de 390 km. Levando em conta o percurso ida e volta, o valor do combustível necessário para uma viagem dessas e que na época dos fatos não havia pedágios funcionando no Paraná, não é crível que a despesa exigida para uma viagem dessas supere os R\$ 500. Segundo, porque Everton gastaria apenas aproximadamente R\$ 150 com uma passagem de ônibus de Bauru até seu destino, caso viajasse pela mesma forma alegada por Reginaldo.

Ademais, a testemunha André reafirmou em juízo que o veículo C4 Pallas passou pela praça de pedágio em alta velocidade, pouco depois da abordagem do Ford Fusion, em que estavam Everton e Reginaldo. Seria uma coincidência inverossímil os corréus terem saído de Maringá praticamente ao mesmo tempo, sem um saber quando o outro sairia, e mesmo assim ambos terem passado quase no mesmo momento por pelo menos dois postos de pedágio, com o veículo carregado de drogas exatamente após o batedor.

Outras circunstâncias estranhas verificadas nos autos demonstram que os réus buscam ocultar a verdade dos fatos. A fl.28 foi juntado comprovante de um restaurante, encontrado dentro do veículo C4 Pallas e datado de 15/07/2022, às 00h53 que deixa claro, pelos itens adquiridos, que Leonardo não seguia viagem sozinho como tentou convencer.

Pelo extrato de fl.171 nota-se que pouco antes de serem abordados os veículos também passaram em horários próximos pela praça de pedágio de Rancharia, sendo que da mesma forma primeiro passou o veículo Ford Fusion e após 10 minutos, o veículo C4 Pallas.

Além disso, em audiência as Defesas concordaram com a realização de perícia no celular apreendido com Reginaldo, protegido com senha, porém ele se negou a fornecer os dados, alegando que não se recorda mais da senha, o que é improvável eis que desde a data dos fatos até o dia da audiência passaram-se menos de 3 meses. É certo que Reginaldo buscou esconder conteúdo do aparelho que poderia lhe comprometer.

A testemunha Elizabeth, avó da filha do réu Everton contou história diferente dos autos. Acerca do Ford Fusion alegou que o réu tinha mandado arrumar o carro e foi buscar, o veículo estava naquela cidade, asseverou que depois da pandemia o réu fazia bicos e ficou parado, só tinha aquele carro que estava estragado. Já os réus afirmaram que o veículo havia sido vendido para uma garagem e o negócio foi desfeito. Elizabeth relatou que Everton ficou dois dias na sua casa, todavia, da forma como os fatos foram narrados nos autos, eles viajaram no dia 14/07/2022 e voltaram logo no dia 15/07/2022, quando foram surpreendidos na praça de pedágio. Reginaldo e Everton também foram contraditórios quanto à data da viagem de Reginaldo, demonstrando mais uma mentira dos acusados. Reginaldo disse que viajou

para Maringá, a pedido de Everton, um dia antes da prisão, no dia 14/07, enquanto Everton disse em seu interrogatório que Reginaldo já estava naquela urbe há dois dias, para acompanhar a vistoria.

Acrescento que em juízo a testemunha André mencionou que no momento da abordagem do Ford Fusion na praça de pedágios, Everton e Reginaldo deram versões desencontradas acerca do motivo da viagem, o que é mais indicativo de que os réus mentiram.

No mais, as combativas Defesas de Reginaldo e Everton sequer fizeram prova do suposto negócio jurídico firmado com relação ao Ford Fusion, o que poderia ter sido esclarecido com a simples juntada da suposta vistoria realizada ou arrolamento do dono da garagem como testemunha. Reginaldo poderia facilmente ter provado que viajou para Maringá de ônibus juntando cópia do bilhete da passagem, mas também permaneceu inerte.

É claro que o ônus da prova incumbe a quem acusa, e o Ministério Público trouxe elementos a contento para convencer que os réus são culpados, ao passo que os réus não fizeram esforços para comprovar seu álibi, o que deixa a versão deles isolada do restante do conjunto probatório e não é digna de credibilidade.

Assim, a confissão extrajudicial de Leonardo, em consonância com as informações pretéritas recebidas pelos policiais e os relatos deles, quando ouvidos em solo policial e André também em juízo; a mudança injustificada na versão contada pelo réu Leonardo; e a apreensão de grande quantidade de maconha no veículo C4 Pallas, deixam claro que eles tinham ciência do transporte e da função de batedor exercida por Everton e Reginaldo.

Com relação à causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, esta resultou caracterizada. A prova oral colhida é harmônica e convincente no sentido de que ambos os veículos vieram do Estado do Paraná, um com drogas e outro na função de batedor.

Outrossim, é caso de perdimento do dinheiro apreendido nos autos, pela ausência de origem lícita, e do veículo Ford Fusion, pertencente a Everton, pois utilizado para a prática do crime de tráfico de drogas. Ressalto que o E. Supremo Tribunal Federal fixou, em sede de repercussão geral, a tese de que: “é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal” (RE 638.491/PR, rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j.17/05/2017).

O perdimento de bem oriundo de crime de tráfico é corolário da condenação, com suporte em determinação legal e constitucional (art. 63 da Lei 11.343/06 e art. 243 da Carta Magna). Ressalto que a legislação pertinente - inclusive a Constituição Federal -, não prevê a necessidade de frequência da sua utilização no transporte de droga e, tampouco, que seja modificado ou preparado para tal fim (TJPR - ACR: 7186174 PR 0718617-4, Relator: Jefferson Alberto Johnsson, Julgamento: 27/01/2011, 3ª Câmara Criminal, Publicação: DJ: 567).

Quanto ao veículo C4 Pallas, restou comprovado que pertence à avó do réu Leonardo, terceira de boa-fé que não tinha ciência da utilização de seu carro na prática criminosa, razão pela qual determino a sua restituição.

Destarte, o conjunto probatório é suficientemente harmônico e coeso a ponto de legitimar o decreto de condenação de todos os requeridos pelo crime de tráfico de drogas, não sendo o caso de aplicação do princípio in dubio pro reo.

Respeitado o sistema trifásico, estabelecido na Constituição Federal, e considerando as diretrizes estipuladas pelos artigos 59 e 60 do Código Penal, passo a dosagem das penas, eis que não milita em favor dos acusados qualquer dirimente:

a) Réu Everton Ribeiro de Moraes:

Consoante a inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena (STF, HC 127241/SP, rel. Min. Dias Toffoli, julgado 04-08-2015, STF, RHC 117489/MS, Rel. Min. Rosa Weber, julgado 18-06-2013) e constituem fundamentos idôneos para fixar a pena-base acima do mínimo legal (STF, RHC 122598, Rel. Min. Teori Zavaski,

julgado em 14-10-14). A culpabilidade, entendida como índice de reprovabilidade da conduta, é de elevadíssima intensidade pela quantia de droga apreendida (aproximadamente 67kg de maconha). A quantidade do entorpecente apreendido revela o dolo exacerbado a exigir certo incremento da basilar, nos termos do artigo 42 da Lei nº. 11.343/06, possibilitando a circunstância de o agente atingir maior número de usuários, de modo a contribuir sobremaneira com a disseminação do vício e correlata destruição de lares ou famílias. Ele é reincidente e ostenta mau antecedente por outro crime (fls.246/248), o que pode ser computado nesta fase processual sem caracterizar o bis in idem por se tratar de fato distinto. Ressalto que o Supremo Tribunal Federal decidiu que condenações criminais extintas há mais de cinco anos podem ser consideradas como maus antecedentes para a fixação da pena-base em novo processo criminal. De acordo com o entendimento, o instituto dos maus antecedentes não é utilizado para a formação da culpa, mas para subsidiar a discricionariedade do julgador na fase de dosimetria da pena, quando já houve a condenação. A decisão se deu por maioria de votos no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 593818, com repercussão geral reconhecida (Tema 150), na sessão virtual encerrada em 17/8/2020. No mesmo sentido é o entendimento do STJ: "O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes" HC n. 337.068/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 28/6/2016. Ainda, menciono: HC n. 413.693/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 16/10/2017" (STJ, AgRg no HC 455.563/MS, 5ª Turma do STJ, Rel. Félix Fischer, j. 18/10/2018). Os motivos e circunstâncias do crime foram inerentes ao tipo penal.

Quanto à personalidade do agente – que no entender de Guilherme Nucci é aquela vinculada às qualidades morais, às distorções de caráter, à índole do sujeito, que são extraídos de sua forma habitual de ser, agir e reagir (in Individualização da Pena, RT, 2005, p.207) – esta é considerada desviada da moral média. Merece maior censura o fato de Everton ter mentido em Juízo, contando versão totalmente dissociada da realidade. Essa atitude demonstra distorção de caráter e a ausência de senso moral pelo réu, que se vale da mentira com o propósito de impor tumulto à instrução processual e maliciosamente induzir em erro o julgador, afrontando a dignidade da Justiça.

Esclareço que a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica e o Código de Processo Penal apenas cancelam que a pessoa não seja compelida a produzir prova contra si e que permaneça em silêncio no interrogatório. Não há previsão legal que autorize a mentira e a obstrução da justiça. Isso porque é princípio basilar que quando não existem dúvidas sobre o texto legal (expressões unívocas) inexistente espaço para que o intérprete busque alterar o seu sentido. A utilização da hermenêutica só se legitima diante da presença de dúvida sobre o conteúdo do texto das normas. Quando não há possibilidade de diversidade de interpretações ao texto legal não se pode buscar alterar o seu sentido a pretexto de hermenêutica, sob pena de se usurpar a competência do Poder Legislativo. Certamente não foi a intenção do legislador outorgar licença para mentir, visando injusta absolvição.

Sobre a questão, oportuno ressaltar que, ainda que o interrogatório seja um meio de defesa e de prova, evidente que o réu deva respeitar as limitações impostas pelas regras do processo, especialmente aquelas decorrentes da lealdade, da ética, da boa-fé, não se podendo esquecer que o processo é um instrumento para realização da justiça, dotado de uma série de formalidades que, em ultima ratio, são verdadeiras garantias para o réu e para a sociedade. É forçoso reconhecer que o réu ao mentir deliberadamente extrapola os limites da autodefesa – que não é absoluta – demonstrando torpeza e deslealdade processual, expondo a risco a justiça que pode, em razão de seu proceder, proferir decisão equivocada e, assim, injusta. Pertinente o registro da lição de Andrey Borges de Mendonça (Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais, 2011, Método, p. 194): "Parece-nos, assim, que se o

juiz constatar que o réu mentiu, poderá considerar tal circunstância no momento da pena. Não é que se esteja estimulando a confessar – até porque para isto já há uma circunstância atenuante genérica -, mas apenas negando que ao juiz e ao Poder Judiciário possa se admitir que o réu venha em juízo e, perante um agente do Estado, possa mentir livremente, como se isto fosse algo normal e aceitável, como se entende atualmente”.

Ainda sobre o tema, vale citar parte do artigo "A mentira do réu como elemento relevante na dosagem da pena", do Promotor de Justiça Dr. Cleber Pereira Defina:

"...assim como a confissão dos fatos denota aspecto louvável da personalidade do agente, pois atua com boa-fé e consciência social, o inverso também é verdadeiro: a mentira do agente sinaliza aspecto censurável de sua personalidade, pois atua com má-fé e franca ausência de consciência social, constituindo-se, portanto, em dado sensível quando da individualização da pena. O indivíduo que mente à autoridade só pretende beneficiar-se com a própria torpeza, conduz ao indesejável erro judiciário, prejudica o direito das vítimas e mina a justiça. Este cenário ratifica a deformação dos valores carregados pelo acusado pinoquista, repercutindo em necessidade ainda maior de reconstituição da tábua de valores socialmente almejada em relação ao acusado enganador. Ora, se é justo que a postura de lealdade do imputado deve surtir efeito no sentido de diminuir sua reprimenda, porque atrelada a condições favoráveis de sua personalidade, segue-se clarivamente que há mesma justiça em extrair efeito no sentido de agravar a reprimenda do réu que ostenta péssima personalidade caracterizada pela insolência de mentir perante as autoridades que colheram sua versão dos fatos, especialmente quando a este acusado lhe foi garantido o direito ao silêncio. Aliás, onde o silêncio for útil, não se justifica a mentira. O mesmo Estado que garante ao processado o direito ao silêncio, a possibilidade de não se autoincriminar, que pode criar recompensas para este falar, como é o caso da atenuante da confissão e do acordo da delação premiada, também deve poder intensificar a reprimenda daquele que ousa falar com o exclusivo propósito de enganar e promover injustiça. O embuste, tanto quanto a lealdade, é vetor a moldar a pena justa, pois ambos dizem respeito à personalidade refletida do agente"

(http://www.esmp.sp.gov.br/revista_esmp/index.php/RJESMPSP/article/view/148/68, acesso em 14 de setembro de 2022, destaquei).

Em suma, todo acusado tem o sagrado e inafastável direito ao silêncio, que decorre da garantia democrática de que ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo (nemo tenetur se detegere ou privilege against self incrimination). Contudo, tal direito não pode admitir a interpretação que alguns lhe emprestam de tornar aceitável, ou pior, irrelevante, a conduta comissiva de mentir, que é vil, antiética e contrária aos valores mais mezinhas da sociedade. Ao revés, deve o julgador, caso constatado que o réu mentiu ao ser interrogado, fixar a pena-base em patamar superior ao mínimo, amparado na personalidade negativa do acusado, pois evidente a ausência de senso moral, denotando índole desviada e personalidade distorcida, daquele que podendo se calar opta deliberadamente por mentir em juízo. A consideração da mentira na ocasião da dosimetria da sentença tem sido aceita pela jurisprudência, conforme voto da lavra do ilustre Desembargador José Raul Gavião de Almeida: "...Se o réu optar por falar, no interrogatório, deverá medir suas palavras, porque elas poderão ser utilizadas também em seu desfavor. É o que ocorre na hipótese do acusado apresentar versão contrária ao convincente conjunto probatório. Identificado que faltou com a verdade, esse comportamento e o teor da inexactidão podem ser considerados pelo julgador, pois não existe direito à mentira, como não há a correspondente obrigação de ignorar a verdade" (TJSP, Apelação 00771651-20.2015, 6ª Câmara de Direito Criminal, j.30/11/2017 destaquei). Tal elemento também foi destacado no voto do eminente Desembargador Tetsuzo Namba: "...demaís disso, se eles tinham a opção de confessar ou ficar em silêncio, no momento que se pronunciavam, suas palavras devem ser ponderadas, se mentem, como no caso dos autos, isso não pode ficar sem avaliação valorativa negativa, sob pena de deixar de lado quem, muitas vezes, colabora com a Justiça e diz a verdade, seria o

patrocínio indevido da "não verdade", isso mostra o caráter de alguém, flagrado no cometimento de infração penal, não se arrepende, ao contrário, faz de tudo para se livrar das imputações... (TJSP, Apelação Criminal 0001611-29.2018.8.26.0625, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j. 28/11/2019, destaquei).

Ainda sobre a mentira do réu como circunstância desfavorável, o exmo. Des. Zorzi Rocha anotou que: "se o réu mentir em seu interrogatório, negando a prática do crime por ele cometido, ou explicando o crime ao apresentar uma versão fantasiosa do fato, tudo a fim de se obter uma injusta absolvição, justificado está o aumento de sua pena-base com fundamento na personalidade negativa. Afinal, a insinceridade e a desonestidade demonstradas perante o Juiz – como explanado no item 2 suso exposto – revelam distorção de caráter e ausência de sendo moral por parte do Réu, que se utilizou da mentira – subterfúgio repugnado pela ética e pelo dever de lealdade – com nítido propósito de tumultuar a instrução processual e induzir em erro o julgador, afrontando, assim, a dignidade da Justiça" (TJSP – Apelação Criminal 0001317-32.2017.8.26.0618, 6.^a Câmara de Direito Criminal, j. 3.10.2019, destaquei).

Com muita razão a ilustre Desembargadora Ivana David manteve aumento de pena por este motivo: "É escorregadia a majoração praticada, uma vez que ao mentir em juízo, a acusada foi muito além do seu direito ao silêncio, mentindo para a Justiça, tentando se esquivar das consequências dos seus atos, porquanto, "nosso ordenamento jurídico, amparado por tratados internacionais e na linha de todos os demais sistemas penais do mundo garantem ao acusado o direito ao silêncio. Significa dizer que o réu, silenciando-se, não pode ser acusado com base nesse fundamento, isto é, ausente provas contra o réu, ele não pode ser condenado porque ficou em silêncio. O momento algum o direito ao silêncio confunde-se com direito a mentira. O silêncio é uma conduta passiva, fundada no direito de não produção de prova contra si. A mentira é conduta ativa, é a produção de prova falsa em juízo", demonstrando, com isso, além da má índole, que o crime não constituiu um episódio acidental em sua vida. (TJSP, Apelação Criminal nº 0000037-05.2017.8.26.0625, 4.^a Câmara de Direito Criminal, j. 10/12/19, destaquei).

No mesmo sentido cito outros julgados do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo: Apelação Criminal 0011154-90.2017.8.26.0625; Rel. Des.: Machado de Andrade; 6.^a Câmara de Direito Criminal; j.: 25/04/2022; Apelação nº 0000129-67.2018.8.26.0618, rel. Des. Roberto Porto, 8.^a Câmara de Direito Criminal, j.29/11/2018; Apelação nº 0000640-36.2016.8.26.0618, rel. Des. Walter da Silva, 14.^a Câmara Criminal, j.28/03/2019.

Na primeira fase, considerando a existência de três elementos negativos (culpabilidade, mau antecedente e personalidade), fixo a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase não há atenuantes a considerar. Está presente a agravante da reincidência (fls.246), prevista nos arts. 61, I, e 63, ambos do Código Penal, razão pela qual agravo a pena do crime em 1/6 (um sexto), elevando-a ao patamar de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase não está prevista a causa de diminuição por não estar caracterizada a situação prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas, diante da reincidência do acusado, demonstrando a dedicação às atividades criminosas. Por outro lado, incide a causa de aumento do art. 40, inc. V, da Lei 11.343/06, tendo em vista a prática do tráfico interestadual, motivo pelo qual majoro a pena em 1/6 (um sexto) e a torno definitiva em 10 (dez) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e pagamento de 1020 (um mil e vinte) dias-multa, cada qual no mínimo legal, em face falta de informação sobre a renda dele, valor que deverá ser atualizado monetariamente até o efetivo pagamento, de acordo com o art. 49, caput, e § 2º c/c o art. 60, caput, ambos do Código Penal.

O regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o fechado, ex vi do montante da pena, do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e da regra constitucional prevista no art. 5º, inc. XLIII da Constituição Federal, e de uma política criminal mais rigorosa de repressão aos crimes de tráfico. Justifico a

fixação do regime prisional mais gravoso, a não substituição por pena restritiva de direitos e a suspensão condicional da pena seja pela reincidência, a indicar um envolvimento reiterado com este tipo de crime; seja pelo montante da pena; seja pelo fato de estarem ausentes os requisitos dos arts. 44, III, e 77, II, do Código Penal; seja porque o art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 estabelece que a reprimenda por crime de tráfico de drogas deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado; seja porque o art. 5º, XLIII, da CF/88, estabelece que a lei deverá dispensar tratamento mais gravoso ao crime em questão